

หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

เนื่องจากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองจำเป็นที่จะต้องมีการใช้อำนาจหรือใช้อุปกรณ์ รวมทั้งอาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวโดยปกติแล้วหน่วยงานทางปกครองมักจะดำเนินการโดยวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ซึ่งต้องมีการทำสัญญากับฝ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยอาจจะเป็นการจัดทำสัญญาในรูปแบบของสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครองก็ได้ แต่โดยที่ระบบกฎหมายของประเทศไทยที่ผ่านมานั้นยังไม่มีหลักเรื่องสัญญาทางปกครองที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาด้วยกันเอง หรือหน่วยงานของรัฐทำสัญญากับเอกชนภายในขอบเขตของกฎหมายมหาชน ดังนั้น สัญญาที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่า สัญญาให้เช่า หรือสัญญาสัมปทาน ก็มักจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาภายใต้ระบบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันทำให้แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาไม่มีความแตกต่างระหว่างสัญญาที่รัฐทำกับเอกชนหรือสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกัน^๑ กล่าวคือ ในเรื่องสัญญาภาครัฐนั้น นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาย่อมเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการและข้อกำหนดในสัญญา แต่หากไม่มีข้อบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว ศาลฎีกามีแนวโน้มที่จะใช้หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับแก่สัญญา^๒

อย่างไรก็ตาม นับแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไปแล้วเป็นจำนวนมาก อันนำไปสู่การวางหลักกฎหมายที่สำคัญของสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนภายใต้ระบบ

^๑ นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๐), หน้า ๔๒.

^๒ ฤทัย หงส์ศิริ, “การนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมาใช้บังคับแก่สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะในประเทศไทย”, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๑๘ ตอน ๑ (เมษายน ๒๕๔๒), หน้า ๖๐-๖๗.

กฎหมายมหาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาของฝ่ายปกครอง โดยมีทั้งกรณีที่ศาลปกครองได้อนุโลมนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นหลักกฎหมายที่เกิดจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เอกสารฉบับนี้จึงนำเสนอโดยแยกตามประเด็นพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำสัญญาทางปกครอง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๑ การจัดทำสัญญาทางปกครอง

ในการเกิดขึ้นของสัญญานั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองกันก่อนที่จะตกลงทำสัญญา หรือการตกลงลงนามในเอกสารสัญญานับเดียวกัน หรือโดยการแลกเปลี่ยนเจตนา ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่เรารู้จักกันในรูปของคำเสนอหรือคำสนองที่ต้องตรงกัน แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญาจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดก็ตาม ก็ย่อมอยู่ภายใต้หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ว่าประมวลกฎหมายดังกล่าวจะมีได้บัญญัตินิยามของสัญญาไว้อย่างชัดเจนก็ตาม แต่ก็สามารถสรุปได้ว่า “สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สันองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มีมุ่งจะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง หรือระงับนิติสัมพันธ์”^๓

จากความหมายของสัญญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา^๔ นั้น ประกอบด้วย

๑) บุคคล ซึ่งเราเรียกว่า “คู่สัญญา” กล่าวคือ เป็นผู้ทำสัญญาเพื่อที่จะสร้างนิติสัมพันธ์และให้ผลของสัญญาที่เกิดขึ้นนั้นตกแก่ตน การจะมองว่าใครเป็นคู่สัญญา

^๓ ศนันท์กรณ (จำปี) โสทธิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๒), หน้า ๒๕๓.

^๔ ศนันท์กรณ (จำปี) โสทธิพันธุ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖๓-๒๖๘.



หรือไม่นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคคลซึ่งมิใช่คู่สัญญาจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากสัญญาได้ ในทางกลับกันหากเป็นบุคคลที่เป็นคู่สัญญา ก็จะมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาและเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

๒) **วัตถุประสงค์** เป็นเป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่จะได้จากสัญญา โดยในสัญญานั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์เสมอ แต่วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจแปรเปลี่ยนหลากหลายไปตามสัญญาโดยอาศัยหลักเรื่องเสรีภาพในการทำสัญญาก็ได้ ซึ่งจะมีข้อจำกัดก็แต่เพียงว่า วัตถุประสงค์นั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เท่านั้น

๓) **เจตนา** สำหรับเจตนาในการทำสัญญานั้น ในเบื้องต้นต้องเป็นเจตนาที่ไม่วิปริตเพราะความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน เพราะถูกกลฉ้อฉล หรือเพราะการข่มขู่ ทั้งยังต้องเป็นเจตนาที่แท้จริง และวิธีการในการแสดงเจตนาก็ต้องเป็นไปตามหลักนิติกรรม โดยอาจแสดงเจตนาด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ และต้องเป็นการแสดงเจตนาที่ตรงกับในใจจริง กล่าวคือ กระบวนการในการก่อเจตนา ทำคำเสนอหรือทำคำสนองจะต้องเกิดจากกระบวนการที่สมบูรณ์ และเป็นคำเสนอ คำสนองที่ต้องตรงกัน

๔) **แบบ หรือวิธีการในการแสดงเจตนา** ซึ่งอาจเป็นวิธีใดก็ได้ไม่ว่าด้วยวาจา กิริยาอาการหรือลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน หรือด้วยการกระทำที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาก็ได้ ยกเว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้สัญญาบางประเภทต้องทำตามแบบ เฉพาะ มิฉะนั้นสัญญาจะตกเป็นโมฆะก็ต้องทำตามนั้น เช่น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

สำหรับสัญญาทางปกครองนั้น ถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ในการจัดทำสัญญาทางปกครองจึงย่อมสามารถนำหลักการข้างต้นมาใช้ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสัญญาทางปกครอง จึงได้สรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมานำเสนอไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

